

1500082-29.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... dúvidas de que ele praticava o nefasto tráfico ilícito de drogas, fazendo-o entre Estados da Federação, posto que saiu do Paraná e foi detido em São Paulo, de modo que essa causa de aumento de pena também é inquestionável e confirmada pelo acusado.

Ainda que o réu tenha confessado o delito, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500082-29.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000044

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2006930/2022 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson da Silva Borges

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

ANDERSON DA SILVA BORGES, qualificado a fls. 09, está sendo processado como incurso no artigo o artigo 33, "caput" c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 do Código Penal, porque no dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 15h30, na Rua Caramuru, n.º 1206, bairro Conceição, nesta cidade de Diadema, guardava e transportava, entre diferentes Estados da Federação, para fins de entrega a consumo de terceiros, 360 porções da droga Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", em formato de tijolos, com peso total de 355,98 Kg (trezentos e cinquenta e cinco quilogramas e novecentos e oitenta miligramas), conforme auto de apreensão e exibição de fls. 23/24, laudo de constatação provisória de fls. 27/28 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 222/223, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 10/03/2022 (fl.293), sem proposta de transação penal. Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.48/51), seguiu-se com a notificação e citação do réu (fl. 322), sendo ofertada defesa inicial as fls.244/253 pelo d. Advogado constituído.

Em audiência una foram ouvidas as testemunhas arroladas tempestivamente pelas Partes, e interrogado o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, entendendo que a pena base deva ser fixada bem acima do mínimo legal diante da excessiva quantidade de drogas, sem possibilidade de redução da pena nem sua substituição, a cumprida em regime fechado, sem direito de apelo em liberdade, somado à perda do veículo e da carga apreendidos, pois produtos do crime.

Já o d. Advogado particular pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, *com a atenuante da confissão, fixando-se regime mais brando (semiaberto) e com direito de apelo em liberdade. É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem no auto de exibição e apreensão de fls.23/24, auto de constatação e definitivo, ambos positivos para as drogas maconha(às fls. 28/30, 210/213, 221/223 e 298/301).

A autoria é inconteste conforme prova que sigo analisando.

Os policiais civis afirmaram em solo pré-processual (fls.2 e 3) que obtiveram a informação de que um caminhão de cor azul, de placas ACA0522 - Douradina/ PR, faria o transporte de uma grande quantidade de drogas (maconha) da cidade de Umuarama/PR para este Estado de São Paulo, para abastecer a região do ABCD paulista, sendo que a viagem estaria programada para o início da manhã do dia 07/01/2022. Diante de tais informações, na data de hoje, o depoente e seu colega de trabalho, o policial Adriano Moreira Ponte se dirigiram para a Rodovia Castelo Branco, na altura do KM 40, sendo que por volta das 15:30 horas, visualizaram o caminhão com as características informadas, tendo abordado o motorista do referido caminhão, o qual parou e se identificou como sendo ANDERSON DA SILVA BORGES. Que ANDERSON apresentou a sua documentação, a documentação do veículo, e ao ser indagado sobre o transporte, o mesmo alegou estar transportando colchões e BOX, da cidade de Umuarama/PR para o Estado de São Paulo, sendo que as entregas seriam em 05 clientes diferentes, conforme as notas fiscais apresentadas. Que indagado se estaria transportando drogas, Anderson negou. E ao realizar uma rápida revista, nada de ilícito foi localizado, em razão do baú do caminhão estar totalmente cheio de mercadorias, dificultando o acesso para uma revista mais minuciosa nos produtos transportados, ou mesmo nos compartimentos do baú. Que Anderson se prontificou em conduzir o caminhão até o primeiro cliente, para a primeira entrega que seria no Bairro da Lapa/ Capital São Paulo, no endereço Rua Monteiro de Mello, 208, e lá chegando, o proprietário do comércio alegou desconhecer tal pedido, bem como, o fornecedor das mercadorias. Mediante a falsidade constante da primeira nota fiscal, os policiais decidiram trazer o caminhão com a carga e o motorista até esta Delegacia Especializada para averiguar com mais precisão toda a carga transportada. Nesta Delegacia Especializada, foi realizada uma vistoria minuciosa no caminhão, e ao retirar a carga do baú, foi localizada uma grande quantidade de droga (maconha), 360 tijolos armazenados em fardos, os quais se encontravam entre os colchões e os

box. Que diante de tais fatos, foi proferida voz de prisão em flagrante delito para ANDERSON DA SILVA BORGES, pelo crime de tráfico de drogas.

Em juízo o policial José Rafael Andrade reiterou que através de investigações e informações obtiveram notícia de que um caminhão cuja placa foi passada estava transportando drogas de outro estado para SP. Localizaram o caminhão, o abordaram, o réu era o piloto e disse que transportava colchões e desconhecia haver drogas em seu interior. Foram até uma loja de entrega e o dono disse que não tinha nada para receber e nem vendia aquela marca de colchão. Encoaminharam o réu ao DP e lá, em revista minuciosa, constatarem os tijolos de drogas no meio da carga. Reconhece o réu.

Neste sentido foi o depoimento do policial Adriano Moreira Ponte alegou ter chegado uma placa de um veículo vindo de outro estado para SP com grande quantidade de drogas. Verificaram que o caminhão estava no estado de SP e foram até a Rod. Castelo Branco. Abordaram o motorista, quem não resistiu. Questionado se tinha algo de ilícito, ele disse que não, só colchões. Que a entrega seria na Lapa. O acompanharam. O dono da loja desconhecia a entrega. Então o levaram ao DP e dentro do baú do caminhão estavam as drogas. A loja a que foram era de colchão, mas não vendiam aquela marca. O réu disse que não havia acompanhado o carregamento, e o caminhão não era dele, só ia fazer o frete, e aceitou porque precisava de dinheiro, e seria um bico.

O réu, extrajudicialmente (fl.04), na presença de sua defensora Dra. PAULA FREITAS DA SILVA - RG. 34.018.418-8 SSP/SP, inscrita na OAB sob nº 302157, com escritório na Rua Sebastião da Silva Bueno, 33 - Ponte Rasa - São Paulo / SP - Fone: 2280-2727, às perguntas respondeu: QUE é motorista autônomo, e no dia 06/01/22 fechou um frete com a empresa Tatiane dos Santos Lima -Estofados, localizada na Rua das Indústrias, 170 - Jd Araçatuba - Douradina / PR., tendo como Responsável pela empresa, o Sr. Pedro, e que o frete seria para transportar BOX e Colchões, da cidade de Douradina / PR para o Estado de São Paulo, cuja a entrega seria em 05 clientes diferentes, conforme Notas Fiscais, sendo que ganharia o valor de R\$ 500,00 pelo frete, esclarecendo que o frete seria realizado com o caminhão da empresa, de placas ACA0522 - Douradina/ PR; Que na data de hoje, por volta das 06:00 horas pegou o caminhão que já se encontrava carregado com as mercadorias, passou no posto para abastecer o caminhão e seguiu viagem rumo ao Estado de São Paulo; Que o interrogado declara que na altura do Km 40 da Rodovia Castelo Branco, foi abordado por policiais, os quais o indagaram se o mesmo estaria transportando drogas, tendo o interrogado respondido que não, apresentando aos policiais as notas fiscais das mercadorias transportadas, como também abriu as portas do baú do caminhão para os policiais fiscalizarem as mercadorias, sendo que nesse momento nada de irregular ou de ilícito foi localizado; Que o interrogado se prontificou em levar os policiais até o primeiro cliente, o qual seria entregue parte das mercadorias, e lá chegando, no endereço constante da Nota Fiscal - ou seja, na Rua Monteiro de Melo, 208 Bairro Lapa - São Paulo, onde o proprietário do comércio disse não tinha conhecimento daquela entrega; Que em seguida, os policiais decidiram trazer o interrogado até esta Delegacia, o qual veio conduzindo o caminhão, e após terem feito uma revista minuciosa no interior do baú do caminhão, localizaram uma grande quantidade de drogas (maconha) entre as mercadorias. Que o interrogado não tinha conhecimento das drogas, alegando que quando pegou o caminhão, o mesmo já estava carregado, portanto não sabia que entre os colchões e box haviam drogas, e que o mesmo é inocente, negando qualquer tipo de envolvimento com as drogas localizadas; Que o interrogado alega que nunca teve qualquer passagem por drogas.

Sob o crivo do contraditório o acusado confessou que o caminhão era seu e que foi contratado para levar colchões do Paraná para SP e sabia que no meio deles teria eletrônicos. Deixou o caminhão para ser carregado e no dia seguinte foi que lhe disseram que na verdade levaria drogas e não eletrônicos, mas como já sabia que

levaria algo diverso, mesmo sabendo que não seria mais eletrônicos e sim drogas, mas por estar precisando de dinheiro, pois ganharia cinco mil reais pelo transporte, aceitou o frete.

Logo, o interrogatório com a confissão judicial do réu não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além dos laudos periciais, sem prova contrária.

Ora, como visto, houve uma denúncia que se mostrou verídica no sentido de que um determinado caminhão vindo do Paraná para São Paulo estaria transportando drogas. Tanto que para despistar, trazia colchões e box, mas apurou-se que as notas fiscais eram falsas, dado que já na primeira tentativa de entrega o suposto cliente desconhecia por completo a negociação. E embora o acusado alegue não ter conhecimento de que as drogas estavam no baú do caminhão que pilotava, alegando que este já lhe foi entregue carregado, não é crível que um motorista profissional autônomo não se acautele acerca da mercadoria que transporta, de modo que ao menos assumiu o risco de transportar bem ilícito, sendo assim responsável pelo que estava sob sua guarda, até porque não fez prova de sua versão, como lhe competia o ônus. Pelo contrário, os documentos de fls. 204/207 relativos à carga lícita transportada, além da grande quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, em meio à carga transportada no baú do caminhão conduzido pelo réu, agregados às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que ele praticava o nefasto tráfico ilícito de drogas, fazendo-o entre Estados da Federação, posto que saiu do Paraná e foi detido em São Paulo, de modo que essa causa de aumento de pena também é inquestionável e confirmada pelo acusado.

Ainda que o réu tenha confessado o delito, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para a seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Mesmo que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares transportar e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto tese de estado de necessidade ou de situação de pobreza, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. 'Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos' (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a enorme quantidade da droga e a denúncia anônima que dava conta de seu transporte interestadual, são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, mas por outro lado a excessiva quantidade de narcótico apreendido (356 quilos de maconha), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas e me valendo do princípio da proporcionalidade, ou seja, quanto mais drogas maior a reprimenda, fixo em primeira fase a pena base acima do mínimo, qual seja, 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. E nem se alegue desconhecer o réu o montante de drogas que transportava já que se tratava de um caminhão, de modo que pouca coisa não necessitaria de tanto espaço, caberia numa bolsa ou pochete, além de ser pouco crível que o réu fosse transportar drogas sem saber o que seria nem o quantum, dado que teria que prestar contas, até para caso lhe cobrassem algo ele ter conhecimento e prova de que não pegou nada para si.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes e sim a atenuante da confissão, e tendo sido utilizado o interrogatório como meio de prova de autoria para a fundamentação do presente decreto condenatório, milita em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a reduzir a pena ao mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em terceira etapa, aumento a pena em 1/6 pelo crime ter se operado entre Estados da Federação, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fl. 268), mas considerando tratar-se de tijolos de erva a abastecer várias “biqueiras” de toda a grande região do “ABCDM”, impactando numa grande região geográfica, atingindo milhares de usuários, além da confiança depositada no réu e, portanto, seu maior envolvimento com a mercancia ilícita, e de outra banda a ausência de drogas mais nocivas, opto pelo percentual de 2/5, a reduzir a reprimenda para 03 anos e 06 meses de reclusão e 349 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Incabível a benesse do art. 44 do CP ao réu diante da excessiva quantidade de substâncias entorpecentes, por não se mostrar socialmente recomendável, tratando-se de uma ação de extrema gravidade, pois como já dito, seria para abastecer uma região enorme da grande SP, impactando no vício de milhares de usuários. Some-se a isso o fato de que : ... O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Fixo o regime prisional semiaberto por conta da grande quantidade de droga. Segundo entendimento do STJ já firmado, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e da quantidade da droga. Assim, o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar tais circunstâncias, no caso em tela 360 tijolos da erva, e por isso fixei o regime semiaberto ao caso em tela. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019). Ademais, o réu é primário, não tem nenhum antecedente criminal e já tem certa idade, é confesso, e o delito não foi praticado com violência nem grave ameaça à pessoa.

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de três meses, e sem direito sequer à progressão de regime, considerando a prisão do réu por menos de quatro meses.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Vedo o recurso em liberdade, sendo incongruente soltar o réu, ora condenado a regime que o manterá preso para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC n.º 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC n.º 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC n.º 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC n.º 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado. Mas sim a ser decretada a perda de bens em favor da União, dado que proveniente e produto da traficância ilícita.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra ANDERSON DA SILVA BORGES, qualificado a fls. 09, como incurso no artigo o artigo 33, “caput” c.c. artigo 40,

inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 o faço para condená-lo à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 349 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, em 100 UFESPS ante a constituição de Advogado particular, sem declaração de hipossuficiência até a presente data, nem pedido de concessão da benesse.

O acusado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias e em 60 dias as custas, sob as pena da lei.

Decreto a perda do veículo apreendido, pois usado no tráfico de drogas, assim como o perdimento da carga já que a empresa cujo nome consta nas NFs e o dono do automóvel não responderam ao chamamento processual, e o faço com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06 e Lei 14.322/22 que altera a Lei Antidrogas para excluir a possibilidade de restituição ao lesado do veículo usado para transporte de droga ilícita, e para permitir a alienação ou o uso público do veículo independentemente da habitualidade da prática criminosa, permitindo ainda a doação dos colchões e camas box.

Oficie-se ao IIRGD e TRE, ficando determinada a incineração de todo o entorpecente. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA